

1500252-04.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... não havendo a previsão do crime de tráfico na forma culposa. Argumentou que não foi apresentado motivo para a revista pessoal do réu, sendo ilícita a localização da droga na posse do acusado. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo a pena ser reduzida em seu patamar máximo. Requereu a improcedência da ação.

É o relatório.

Fundamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500252-04.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-04.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015127/2022 - 1º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AHMAD ALI EL MALAT

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

AHMAD ALI EL MALAT, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado como incurso na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Conforme narra a denúncia, no dia 17 de janeiro de 2.022, por volta das 19hs45min, na Rodovia Manuel Hipólito do Rego, altura do km 233 + 300 m, Monte Cabrão, nesta Comarca, o réu trazia consigo as drogas apreendidas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, voltado para a fiscalização de trânsito, quando avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta, placas FZY 6219, razão pela qual entenderam por bem abordá-lo. Na ocasião, depois de perceberem que havia um volume na cintura do réu e terem escutado dizer que estava "carregando coisa errada" "e estava com um pacote", os milicianos receberam do próprio acusado uma sacola contendo uma cerca de 100 gramas de cocaína a granel e uma pedra de "crack" em tamanho considerável (pesando cerca

de 500 gramas).

Consta, ainda, que, indagado pelos policiais, admitiu a prática do tráfico de drogas ao dizendo que levaria as drogas para Bertioga.

Consta, por fim, que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas revelam que o réu trazia consigo as porções de drogas apreendidas com o fim de entregar a terceiros.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04). Boletim de ocorrência (fls. 02/04). Auto de exibição e apreensão (fls. 07/08). Laudo pericial (fls. 76/78).

O réu foi notificado (fls. 88/89) e ofertou defesa prévia (fls. 98/102).

A denúncia foi recebida em 19/04/2022 (fls. 103/105).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público, pugnou pela procedência da ação penal. Disse que o acusado tinha ciência do que transportava. Falou que os policiais esclareceram as circunstâncias da abordagem, bem como onde o réu guardava a droga. Sustentou que a droga encontrada com o réu era destinada ao comércio e consumo de terceiros. Falou que os policiais afirmaram que o réu estava com a droga na cintura, descrevendo as circunstâncias da abordagem e da localização da droga na posse do acusado. Sustentou que os policiais explicaram que no momento da abordagem o acusado disse que estava com coisa errada, quando encontraram a droga na cintura dele, sob as vestes. Narrou que se fosse uma entrega lícita, a encomenda não estaria escondida sob as vestes do acusado, junto à genitália. Aduziu que foi encontrada com o réu grande quantidade de droga, muito superior aquela destinada para o consumo próprio. Sustentou que restaram claras as circunstâncias em que o réu transportava as drogas. Na fixação da pena, afirmou que deve ser observado que o réu não ostentava antecedentes criminais na época dos fatos.

A Defesa, em memoriais (fls. 140/144), requereu a absolvição do acusado. Aduziu que não há provas que o réu tinha a intensão de comercializar a drogas. Argumentou que o acusado não agiu com dolo na prática do delito de tráfico de drogas, sendo apenas contratado para levar uma encomenda até Bertioga. Narrou que ele não pode violar encomendas destinadas a terceiros. Afirmou que incorreu em erro de tipo, pois poderia ser evitado se tivesse verificado o conteúdo da encomenda, o poderia acarretar a punição de crime culposos, sendo atípica a sua conduta, pois não houve dolo, não havendo a previsão do crime de tráfico na forma culposa. Argumentou que não foi apresentado motivo para a revista pessoal do réu, sendo ilícita a localização da droga na posse do acusado. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo a pena ser reduzida em seu patamar máximo. Requereu a improcedência da ação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, pelo laudo pericial dos entorpecentes de fls. 76/78, bem como pela prova oral colhida durante a fase de instrução.

A autoria do delito também é certa e atribuída ao acusado.

A testemunha LUIZ AMÉRICO DOMINGUES DE LIMA, policial militar, disse que estava em uma fiscalização de trânsito, quando foi feita a abordagem de um motociclista.

Disse que o acusado estava longe da direção da motocicleta. Falou que pediu para ele mostrar o documento, quando percebeu que ele estava com um volume na cintura.

Disse que o réu falou que estava com coisa errada e quando pediu para ele mostrar o que estava na cintura, encontrou a droga apreendida. Disse que a droga consistia em um tablete de crack, algumas pedras de crack já destacadas deste tablete e uma porção de pó branco, que parecia ser cocaína. Falou que a porção de pó branco tinha um volume de um sabonete e o tablete de crack tinha o volume um pouco maior que um maço de cigarros. Narrou que o acusado, no momento da abordagem, disse que estava com coisa errada e que estava levando o pacote para Bertioga. Falou que o volume da droga encontrado com o réu era bem superior daquele para consumo pessoal.

Reconheceu o réu como aquele abordado com a droga no dia dos fatos. Disse que a abordagem foi motivada por fiscalização de trânsito, de rotina. Falou que o acusado estava conduzindo a moto normal e quando pediu o documento ele se inclinou e viu o volume, ficando preocupado se ele estivesse armado. Falou que o acusado comentou que estava com algo errado antes da revista pessoal. Disse que o réu falou era motoboy, mas nada comentou de que estava fazendo uma entrega, dizendo apenas que iria levar o pacote para Bertioga. Explicou que não conhecia o acusado antes dos fatos e que não teve contato com ele posteriormente.

A testemunha LUCIANO DAHER DOS SANTOS, policial militar, disse que estava em uma fiscalização de rotina quando o acusado veio na sua direção na rodovia, e que o seu parceiro deu ordem de parada. Falou que após a parada o acusado ficou curvado para frente e que ele disse que tinha coisa errada com ele. Narrou que o acusado estava com um pacote na cintura, por dentro das vestes. Disse que o acusado estava com capa de chuva e o pacote estava dentro da calça, próximo da genitália. Aduziu que foi perguntado sobre a procedência do pacote, quando o acusado falou que recebeu de uma pessoa que não conhecia e que entregaria para outra pessoa que também não conhecia. Falou que o réu estava com uma pedra de crack grande, mas não se recorda o tamanho, e que o pó branco encontrado na posse dele também estava dentro do saco plástico, mas também não se recorda do volume. Disse que a quantidade apreendida com réu não é compatível com o consumo próprio, pois era muito grande. Narrou que o acusado disse que usava entorpecente, mas que na abordagem não falou que a droga era para seu uso. Afirmou que com réu não foram encontrados outros objetos de interesse policial. Reconheceu o réu como a pessoa abordada no dia dos fatos. Falou que estava cerca de 3 metros da abordagem do réu feita pelo seu parceiro e quando chegou mais perto o réu falou que tinha coisa errada com ele. Falou que não conhecia o acusado antes dos fatos, apesar de ele ter falado que já foi em uma festa na companhia onde ele trabalha. Afirmou que o acusado disse que trabalhava de moto táxi e que ele falou que somente estava com aquela entrega para fazer. Disse que tanto na moto quanto no baú da moto nada tinha de modo a demonstrar que ele estava trabalhando fazendo entrega. Disse que o acusado não portava qualquer outro pacote.

O réu, AHMAD ALI EL MALAT, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que não sabia que estava levando drogas. Falou que não tinha sacola, mas estava com uma caixa quadrada amarela e que esta sumiu e que os policiais apareceram com uma sacola preta. Narrou que pegou a caixa do iFood, pelo aplicativo. Disse que eles vieram com uma Fiorino e entregaram a caixa para ele. Aduziu que não se recorda onde entregaram a caixa para ele. Disse que o seguro da empresa cobriu a caixa que os policiais pegaram. Narrou que os policiais rasgaram todos os papéis das suas entregas e que por isso não tem provas. Afirmou que pega as entregas perto de uma padaria, em Guarujá, e que tinha mais duas entregas em Bertioga. Disse que suas declarações que constam na fase policial não são verdadeiras, pois assinou sem ler. Falou que no dia dos fatos fez várias entregas ao longo do dia e que sua mãe residia em Bertioga, e que estava indo visitá-la no dia dos fatos. Argumentou que não tem permissão para abrir os pacotes. Narrou que pegou as entregas na padaria. Disse que atualmente trabalha como segurança, mas não é registrado. Explicou que nunca abriu os pacotes que vai entregar. Disse que a Fiorino que entrega as encomendas não é caracterizada e tem placa de São Paulo.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Vê-se, assim, que as provas colhidas são suficientes para a condenação do réu, pois foi adequadamente comprovado que este trazia consigo as drogas apreendidas para o fim de traficá-las, de forma ilícita.

Neste diapasão, as testemunhas policiais Luiz Américo e Luciano lograram êxito em descrever, de forma harmoniosa, a ação criminosa do réu, relatando que o motivo da abordagem foi uma fiscalização de rotina realizada na rodovia.

A testemunha Luiz Américo afirmou que estava em uma fiscalização de trânsito, quando foi feita a abordagem do acusado, que estava de motocicleta, e, quando ele parou, percebeu que estava longe da direção do veículo. Disse que, ao pedir para que o réu mostrasse o documento, percebeu que ele estava com um volume na cintura, momento que o acusado disse que estava coisa errada e que estava levando o pacote

para Bertioga. Explicou que após essa fala do réu, pediu para ele mostrar o que estava na cintura, encontrando a droga apreendida.

Da mesma forma, a testemunha Luciano corroborou as palavras de Luiz Américo, também narrando a mesma dinâmica dos fatos. Luciano disse que o réu levava o pacote na cintura, por dentro das vestes, e que ele estava com capa de chuva e o pacote estava dentro da calça, próximo da genitália. Falou, ainda, que foi perguntado sobre a procedência do pacote, quando o acusado falou que recebeu de uma pessoa que não conhecia e que entregaria para outra pessoa que também não conhecia. Deste modo restou plenamente configurado que o acusado tinha plena ciência de que levava drogas na sacola que estava em sua posse.

Quanto ao valor do testemunho policial, é digno de notar que o artigo 202 do Código de Processo Penal determina categoricamente que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no artigo 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo ser levado em conta que os agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade, possuindo fé pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive, atribuiu idoneidade e presunção de veracidade à prova prestada por policiais, aduzindo, em entendimento pacificado, que “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC. nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido frequentemente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto: “Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Com efeito, a idoneidade do depoimento policial só poderia ser questionada se houvesse indícios nos autos de injusta incriminação de inocente, o que não ocorre no caso sub examine, até porque as testemunhas relataram que nada tinham contra o acusado, bem como de sequer o conheciam antes dos fatos.

Destarte, da análise dos referidos depoimentos, verifica-se que as testemunhas policiais narraram de forma harmoniosa e convincente todo o contexto de abordagem do réu, não havendo motivos para não dar a eles o devido crédito, não havendo qualquer indício nos autos de injusta incriminação de inocentes. Em contrapartida, não demonstrou o réu motivos plausíveis pelo qual estivesse sendo acusado injustamente.

Assim, não há qualquer verossimilhança na versão do acusado de que os policiais o incriminaram de maneira injusta, de modo que tal versão encontra-se isolada nos autos.

Nesse diapasão, o acusado não comprovou, mesmo que de forma mínima, qualquer de suas alegações, não tendo qualquer documento/comprovante de entrega de encomenda para ele, não sabendo o nome da pessoa que entregou o pacote para ele, bem como o nome de quem iria receber a suposta encomenda. Não soube precisar sequer o local onde retirou a encomenda, somente dizendo que foi em uma padaria em Guarujá e que foi pelo aplicativo iFood, sendo que uma Fiorino, sem qualquer caracterização de empresa, com placa de São Paulo, entregou o pacote para ele, não sabendo fornecer

qualquer detalhe.

Deste modo, a versão apresentada pelo réu não tem qualquer respaldo probatório, não tendo o condão de desconstituir os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas policiais, que descreveram de forma minuciosa como os fatos ocorreram.

Neste interregno, não há qualquer motivo capaz de afastar a credibilidade dos depoimentos das testemunhas policiais. Não há indício, nos autos, de que estes tivessem motivo particular ou injusto para incriminar falsamente o réu. Ademais, são servidores públicos com a função de prevenir e reprimir a prática de crime, de maneira que seria um contrassenso atribuir-lhes a função de combate a delitos e, posteriormente, retirar a credibilidade de seus depoimentos.

"O depoimento de policial, mesmo participante da diligência do flagrante, quando coerente e seguro, é tão valioso como qualquer outro" (RT 593/423).

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT 616/287).

Portanto, da análise dos referidos depoimentos, verifica-se que as testemunhas narraram de forma harmoniosa e convincente a ação criminoso do acusado, de modo que ele levada consigo, escondido sob as suas vestes, próximo à genitália, a sacola onde estava a droga apreendida, de modo que restou patente a propriedade da totalidade da droga pelo réu.

Ademais, apesar de negar a prática delitiva em Juízo, em seu interrogatório prestado na fase policial, o acusado disse que trazia o pacote em sua cintura, pois não tinha onde carregar, já que não estava com mochila.

Deste modo, caso estivesse sendo acusado injustamente de crime que não cometeu, não é crível que, na primeira oportunidade que tivesse, perante a autoridade policial, não iria esclarecer como os fatos efetivamente ocorreram, na sua versão, de modo que apenas falou que trabalha como motoboy, e que iria entregar um pacote e que não sabia o seu conteúdo.

Assim, na fase policial não há qualquer referência a outra caixa ou documentos, de modo que fantasiosa a versão apresentada em Juízo, de que estes foram destruídos pelos policiais que fizeram a abordagem.

Ressalta-se, ainda, que não há mínimo de verossimilhança na afirmação de que as suas declarações prestadas na fase policial não são verdadeiras, pois assinou sem ler, deixando subentendido que houve um conluio entre os policiais que fizeram a abordagem e os policiais que registraram a ocorrência na delegacia de polícia para incriminá-lo, o que beira o absurdo.

Nesse passo, verifico que a versão apresentada pelo acusado restou enfraquecida, cabendo ressaltar que a prova trazida aos autos pela D. Defesa não teve o condão de infirmar toda a prova produzida na instrução criminal.

No mais, também não merece acolhimento a tese defensiva de que a conduta do acusado é atípica, pois não houve dolo na prática do tráfico de drogas. Assim, conforme acima fundamentado, restou claro pelas provas carreadas nos autos que o acusado tinha plena ciência que levava drogas consigo, com o objetivo de traficá-las, não havendo que se falar em ausência de dolo.

Também não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial.

Neste contexto, destaco que a abordagem, de início, foi motivada pela fiscalização regular de trânsito. Foi dada ordem de parada a uma motocicleta. Entretanto, a conduta suspeita do acusado, após parar o seu veículo, que estava com um volume na cintura, chamou a atenção dos agentes públicos, de modo que o próprio réu retirou a sacola da cintura, que estava sob as vestes, e falou para os policiais que estava com "coisa errada", momento que foi localizada a droga em poder do acusado, restando claro que os policiais agiram dentro da legalidade.

De mais a mais, em atenção à quantidade de droga apreendida, bem como à conduta do acusado, é forçoso reconhecer a destinação comercial do entorpecente apreendido e, conseqüentemente, o animus de traficar do acusado.

No caso em análise, o réu trazia consigo a droga, ou seja, praticou uma das ações previstas no caput do tipo penal, estando, portanto, incurso na prática do crime de

tráfico e sujeito às penas a ele culminadas, mesmo que não tenha sido preso em flagrante fazendo a efetiva comercialização do entorpecente.

A atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a traga consigo, especialmente em significativa quantidade, circunstância que evidencia o comércio clandestino.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

(...) 3. É firme o entendimento desta Corte Superior de que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento." (STJ - AgRg no HC: 667338 SP

2021/0151627-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) Outrossim, é cediço que para a consumação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, que vale recordar, se trata de um tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), basta o cometimento de apenas um de seus verbos, quais sejam os de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, afigurando-se, assim, o que se denomina dolo genérico. (...) Conclui-se, assim, que o cometimento do crime de tráfico torna despropositada a própria venda, posto que o crime se consuma com o simples "guardar", "portar" ou "trazer consigo." (STJ - AREsp: 1689986 AM 2020/0085766-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

In casu, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de tráfico de drogas.

Portanto, comprovadas autoria e materialidade delitivas e, não incidindo na espécie nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é imperativo condenar o réu pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à aplicação das penas.

Na primeira fase, atento-me ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 combinado com o artigo 59, do Código Penal. Assim, observo que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, seja 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que mantenho pena do réu em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, por fim, anoto estar presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isto porque, o réu é tecnicamente primário e não há qualquer elemento indicativo de que se dedique às atividades criminosas, bem como integre organização criminosa. Desta feita, presentes os requisitos legais, a pena deve ser reduzida no patamar de 2/3. Portanto, fixo a pena por definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas da ré.

Anoto, no entanto, a possibilidade de se aplicar ao acusado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, tendo em vista que ele preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal.

O Senado Federal, por meio da Resolução n.º 5/12, retirou a vedação contida no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, permitindo aos condenados por tráfico de entorpecentes a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. A jurisprudência também já se estabeleceu nesse mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como da expressão 'vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos', contida no art. 44 do mesmo diploma legal, por ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo possível a pena substitutiva aos traficantes de drogas, desde que preenchidos os pressupostos do art. 44 do Código Penal. 2. No caso concreto, mostra-se viável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos aos agravados, condenados a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, com circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis e sendo pequena a quantidade de material tóxico apreendido - 20 (vinte) pedras de crack e 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg. No Resp 1.330.133-RS, 5ªT., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05/02/13. Precedentes: STJ HC 230.817-SP, STJ HC 273.633-SP , STJ HC 226.312-MT)

E, ainda, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos quando se tratar de tráfico privilegiado, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena. Se não, vejamos:

"Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. Possibilidade. Paciente que cumpre os requisitos previstos no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Aplicação das Súmulas 718 e 719. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC n. 97.256/RS). 6. Necessidade de análise dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7. Superação da Súmula 691. Manifesto constrangimento ilegal. 8. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto de início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais." (HC 133.028 -SP - Min. Gilmar Mendes - Julg. 12.04.2016)

Portanto, no caso dos autos, a substituição se mostra suficiente e a medida socialmente recomendável, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A primeira restritiva consiste no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 45, parágrafo 1º c.c art. 44, § 2º do Código Penal.

A segunda restritiva consiste em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o acusado AHMAD ALI EL MALAT, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, ante a ausência de elementos demonstrativos sobre a capacidade financeira do réu, pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", c/c § 4º do mesmo artigo, ambos da Lei 11.343/2006.

Substituo em favor do réu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um)

salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 45, parágrafo 1º c.c art. 44, § 2º do Código Penal, e em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. Tendo em vista o regime inicial para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, o réu poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, anatem-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei 11.343/06.

Oportunamente, expeça-se o necessário para a cobrança da multa penal imposta. Considerando que o sentenciado foi assistido por advogado dativo nomeado por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais. Anote-se.

Por fim, com relação ao pleito defensivo de restituição do veículo apreendido, observa-se que não restou comprovado que o réu se utilizava da motocicleta para realizar a traficância com habitualidade.

Deste modo, o acusado afirmou que trabalhava como moto boy, utilizando a citada motocicleta como meio de trabalho.

A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à necessidade de demonstração da utilização do bem, de forma habitual, à atividade ilícita ou da comprovação de sua aquisição com o produto do tráfico de drogas para que seja decretado o seu perdimento:

"(...) 3.Tendo o Tribunal de origem consignado, expressamente, que "não restando demonstrado, in casu, que o veículo e os celulares apreendidos foram adquiridos com o produto do tráfico de drogas, tampouco que se destinavam precipuamente, para atividade ilícita", impossível autorizar a ordem de confisco, com fulcro na simples circunstância de apreensão das drogas no veículo, desacompanhada de qualquer outro elemento de convicção quanto a sua origem ou destinação. 4. Agravo a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, Dje 14/11/2012). Grifei.

"(...) 3. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: AgRg no Resp 1185761/MT, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, Dje 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, Dje 14/11/2012 e AgRg no Resp 1053519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, Dje 01/08/2011. 4. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente. 5. Não havendo provas contundentes de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com produto do crime, nem dúvidas da propriedade do bem, a ausência de provas de que o veículo de propriedade da impetrante tivesse sido utilizado em ocasião anterior para a prática do tráfico de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade autoriza a liberação do veículo apreendido. 6. Recurso ordinário a que se dá provimento".

(RMS 50.630/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, Dje 01/08/2016). Grifei.



Neste sentido, não há comprovação de que o réu utilizava a citada motocicleta de forma habitual para a prática do tráfico de drogas, ressaltando-se, inclusive, que aqui foi reconhecida a benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo de rigor o afastamento da decretação de perdimento. Contudo, observa-se que não há nos autos comprovante de propriedade do citado bem, de modo que o pedido de restituição somente poderá ser analisado após o acusado comprovar a titularidade do bem apreendido, juntando a documentação pertinente.

P.I.C.

Santos, 13 de julho de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA